

1502623-75.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Mercancia não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1502623-75.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502623-75.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO BARBOSA DE SOUSA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

MAURÍCIO BARBOSA DE SOUSA e CINTIA CRISTINA BORGES DA COSTA qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, 12 de outubro de 2021, por volta das 14h50min, na Avenida Ráilda Alves de Oliveira, altura do número 228, na via pública, Parque Rodrigo Barreto, cidade e comarca de Arujá, os acusados traziam consigo para fins de venda e efetivamente vendiam drogas, quais sejam, 27 porções de cocaína (massa líquida de 12,7g) e 14 porções de maconha (massa líquida de 27,1g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, os acusados estavam nas arquibancadas de um campo de futebol, com uma certa quantidade de estupefacientes, aguardando a chegada de usuários compradores. Porém, eles foram avistados por policiais militares, que deles suspeitaram. Com a aproximação da viatura policial, a acusada Cíntia dispensou a sacola que estava com eles, derrubando-a atrás das arquibancadas. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles, apenas R\$ 30,00 que estavam com Cíntia. Porém, a sacola por eles dispensada foi recuperada. Dentro dela, havia 14 eppendorfs de cocaína, 13 invólucros também de cocaína e 14 porções de maconha (fls. 100/103).

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02). Boletim de ocorrência (fls. 09/14). Auto

de exibição e apreensão (fls. 15). Laudos periciais (fls. 17/19 e 132/134). Folha de antecedentes (fls. 62/66, 69/70 e 323/328).

Em audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva dos réus (fls. 73/77).

Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 110/115 e 164/171).

Foi concedida liberdade provisória ao réu Maurício nos autos do habeas corpus n. 714829-SP (fls. 179/183), sendo cumprido o alvará de soltura em 16/02/2022 (fls. 210).

Foi recebida a denúncia em 25 de fevereiro de 2022 (fls. 228/229).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogados os réus ao final (fls. 329/334).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais em audiência, postulando pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, na primeira fase aduziu que a pena-base de Cíntia deve ser exasperada em razão dos maus antecedentes e Maurício é tecnicamente primário, mas as circunstâncias são desfavoráveis. Na segunda fase incide a agravante da reincidência quanto a Cíntia. Na terceira fase pleiteou a não aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. Requereu aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso III da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3. Pugnou pela aplicação do regime fechado.

A defesa de Cíntia, por seu turno, em memoriais escritos, aduziu a insuficiência probatória para condenação. Pontuou que houve flagrante preparado.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação para o crime de uso, com aplicação da pena no mínimo legal (fls. 336/350).

A defesa de Maurício, por sua vez, em memoriais escritos, pugnou pela absolvição, alegando que não foi encontrada droga com o réu. Em caso de condenação requereu a fixação da pena no mínimo legal, por ser o réu primário, com aplicação do regime aberto substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observada a detração e assegurado o direito de recorrer em liberdade (fls. 351/358).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O feito está em ordem, não há nulidades a declarar ou irregularidades a serem sanadas.

A presente ação penal comporta parcial procedência.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral.

A autoria em relação a ré Cíntia segue a mesma sorte. No entanto, a autoria do crime com relação a Maurício não restou suficientemente demonstrada.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha Gisnivaune, policial militar, disse que estavam fazendo um patrulhamento tático pelo batalhão de choque. Aduziu que durante o patrulhamento avistaram os dois na arquibancada, no momento em que eles avistaram a viatura tentaram dispensar um pacote de salgadinho e correr, mas não lograram êxito e conseguiram fazer a abordagem. Detalhou que lá era um campo de futebol de várzea e não estava tendo jogo na ocasião, havia um evento de crianças num local um pouco afastado de onde eles estavam. Pontuou que quando eles viram a viatura ficaram agitados, quando abriram a porta ela tentou jogar o pacote para o alto, mas não conseguiu, e tentou jogar novamente. Salientou que na revista pessoal não foi encontrado nada com Maurício. Frisou que quem jogou a sacola foi a mulher. Informou que nas vestes de Cíntia não foi encontrado nada de ilícito, somente R\$ 30,00 em dinheiro.

A testemunha Alexandre disse que estavam em serviço no dia, num patrulhamento tático de choque na região, havia uma festa numa parte do campo de futebol, onde tinham umas crianças e pessoas por lá. Afirmou que numa arquibancada, num lado mais afastado, estavam os dois sentados, quando eles viram a viatura eles começaram a agir de forma estranha e desconfiadamente. Afirmou que quando chegaram perto a

Cintia tentou arremessar um saco de salgadinho por cima do muro da arquibancada e sair do local, mas conseguiram abordá-los. Comentou que dentro do saquinho tinham as drogas, os eppendorfs e pacotes de cocaína, além de invólucros de maconha. Apontou que o local é um campo de futebol e na lateral tem uma arquibancada. Sustentou que era dia das crianças e estavam tendo algumas atividades com as crianças lá, haviam brinquedos, monitores e crianças dentro do campo, na outra extremidade. Externou que quando chegaram ninguém se aproximou deles, só estavam os dois e tentavam sair do local, mas viram que não iam ter êxito porque estavam bem próximos. Observou que não conhecia os acusados porque foi a primeira vez em patrulhamento na cidade. Aduziu que na revista pessoal não foi encontrado nada com o réu Maurício e com a Cintia foi encontrado R\$ 30,00 em dinheiro e fora isso o pacote de salgadinho com o entorpecente. Pontuou que quem arremessou o pacote foi a Cintia. Comentou que a Cintia arremessou a sacola, mas provavelmente por causa do vento ela não conseguiu, a sacola retornou para próximo dela e ela arremessou uma segunda vez, aí ficou bem claro que o pacote estava com ela, depois foi observado que haviam os entorpecentes dentro.

A ré Cintia disse que tem 40 anos, trabalhava catando reciclagem, ganhava R\$ 250,00, estudou até o ensino médio, não é casada e tem quatro filhos, já foi processada por furto e tráfico. Relatou que estava ficando com o Maurício, tinha uns três dias que o havia conhecido, ele sempre ficava no campo de futebol e se conheceram ali. Explanou que Mauricio disse que era para a depoente encostar com ele lá. Falou que aí a polícia chegou, mas o negócio não estava em sua mão e nem na mão dele. Exclamou que estava de top e shorts, não tinha nada consigo, apenas os R\$ 30,00 que era para comprar mistura para sua casa. Apontou que o saco de salgadinho não estava com ninguém, eles acharam atrás da arquibancada. Mencionou que eles estavam passando e fazendo a abordagem deles, não tinham apenas a depoente e Maurício, tinham mais dois rapazes que estavam na frente também, eles seguraram eles e depois soltaram porque a mãe do moleque apareceu lá. Observou que estava de regime aberto, pagou os quatro meses que era para ficar presa e saiu. Noticiou que estava ficando com Maurício, dando uns beijos.

O réu Maurício disse que tem 30 anos, trabalhava como ajudante de manutenção, ganhava R\$ 1.180,00, estudou até a sétima série, é divorciado e tem dois filhos, já foi processado antes por tráfico. Narrou que no dia após as 14h desceu para assistir o futebol, sentou na arquibancada, após os policiais avistaram o depoente que estava sentado. Falou que os policiais perguntaram como estava o campo, o depoente respondeu que era um campo normal, após a abordagem o depoente ficou parado, um outro rapaz correu. Explanou que durante a abordagem viram o alvará de soltura que tinha no bolso, eles viram e falaram que quebrou a cautelar, mas a cautelar era até 18h da tarde. Contou que falaram que estava preso. Externou que mora três ruas depois do campo de futebol. Frisou que não conhecia a Cintia, ela chegou e perguntou como estava o campo de futebol, respondeu que estava tranquilo, após estava aguardando começar o jogo de futebol, a viatura passou uma vez e voltou uma segunda vez, abordou o depoente a Cintia e mais dois rapazes, um deles correu da arquibancada de futebol. Observou que na abordagem não acharam nada em seu poder. Comentou que os policiais falaram que viram a Cintia jogando a sacola, perguntaram de quem era e o que estavam fazendo ali. Disse que quando perguntado falou que ia assistir o jogo de futebol, respondeu que tinha passagem e estava assinando, então eles disseram que estava preso porque quebrou a cautelar. Asseverou que realmente viu Cintia jogando para trás a sacola. Externou que na delegacia ficou com medo e não falou nada, estavam todos juntos na carceragem, homem com mulher. Comentou que não disse nada porque ficou com medo de represálias. Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A materialidade do delito é certa, ante o resultado do laudo pericial que apontou que as substâncias apreendidas consistem em cocaína e maconha.

Em solo policial o réu Maurício alegou não ter qualquer envolvimento com o delito de tráfico que lhe fora imputado e a ré Cintia permaneceu silente (fls. 05/06).

As testemunhas policiais relataram, em síntese, que estavam realizando patrulhamento quando decidiram abordar os réus que estavam na arquibancada do campo de futebol, ao se aproximarem eles tentaram fugir e Cintia tentou jogar uma sacola

por cima do muro, mas a sacola voltou e caiu perto dela, sendo jogada uma segunda vez. Após, em revista, nada de ilícito foi encontrado em poder dos réus, porém na sacola que havia sido arremessada por Cintia foram localizados os entorpecentes. Em juízo o réu Maurício negou o tráfico de drogas. Aduziu que estava no local dos fatos, uma arquibancada de um campo, para assistir o jogo de futebol, quando veio a ser abordado pelos policiais, que ao tomarem conhecimento da passagem criminal anterior do réu o prenderam alegando que teria quebrado a cautelar.

Já a ré Cintia disse que estava ficando com Maurício e foram se encontrar no campo de futebol, não tinha nada consigo e a sacola não lhe pertencia, apenas estava atrás da arquibancada.

A versão exculpatória da acusada Cíntia, em especial no tocante à negativa do tráfico de drogas, não se mostra crível, como será melhor explanado adiante, visto que pela prova colhida nos autos, evidencia-se que a ré possuía drogas para fins de tráfico.

Além do depoimento dos policiais, os quais relataram em uníssono que viram Cintia arremessar, por duas vezes, o saco de salgadinho onde estavam as drogas, o réu Maurício confirmou tal circunstância, dizendo expressamente que viu Cintia jogando a sacola para trás, sacola esta na qual foram encontrados, posteriormente, os entorpecentes descritos na denúncia.

Vê-se que a versão sustentada pela acusada no sentido de que não estava com as drogas apreendidas e que somente estava no local dos fatos por ter ido encontrar Maurício e que não estava com nenhuma sacola não se mostra crível, não tendo trazido a acusada aos autos qualquer elemento de prova passível de gerar alguma dúvida no tocante a sua culpabilidade, e com isso, ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Com efeito, embora não se possa utilizar elementos do inquérito policial como prova, no caso em questão, é a própria versão da acusada em juízo que, contraposta aos relatos dos policiais e às demais provas colhidas, termina por conduzir à certeza de culpabilidade.

Insta obtemperar que a ré apresentou uma versão defensiva muito frágil e pouquíssimo convincente, a qual, por sua vez, acaba oferecendo elementos sobre a abordagem que se coadunam com a dinâmica relatada de forma uníssona pelos policiais e pelo réu Maurício, terminando por constituir um conjunto probatório suficiente à prolação de um decreto condenatório em seu desfavor.

Saliente-se que os policiais afirmaram que não conheciam a ré e que era a primeira oportunidade em que faziam patrulhamento em Arujá, assim não se vislumbram razões para que os policiais buscassem, no caso dos presente feito, incriminar falsamente a acusada no intuito de prejudicá-la gratuitamente.

Desse modo, a condenação da acusada é medida que se impõe.

Ainda, inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente a ré de pena em relação ao delito de tráfico.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois a ré era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

O desfecho dos autos em relação a Maurício, contudo, é distinto.

O réu negou a propriedade da droga com veemência, afirmando que não trazia consigo os entorpecentes, argumentando que foi até o campo para assistir o jogo de futebol. E, embora haja controvérsia sobre o fato de estar se relacionando com Cintia, disto não se pode inferir que estava envolvido na prática do comércio espúrio.

Observo, de outro giro, que nos depoimentos dos policiais estes não informaram terem visto o réu praticando efetivamente tráfico de drogas. Ainda, não há notícia de realização de campana que pudesse permitir aos policiais o acompanhamento de ações que indicassem efetiva prática de comércio de drogas pelo acusado.

Da mesma forma, não se realizou qualquer perícia dactiloscópica confirmando as digitais do acusado na sacola apreendida.

Aliás, neste ponto, cabe observar que, segundo os próprios policiais, nada de ilícito foi encontrado em poder do réu, e a sacola na qual foram localizados os entorpecentes estava em poder de Cíntia e foi por ela arremessada antes da abordagem. Logo, não há como admitir que seja atribuída responsabilidade criminal

ao réu em tais termos.

Vê-se ainda que com o acusado não se localizou, ainda, qualquer quantia em dinheiro ou instrumento para o delito de tráfico de drogas.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é composta por depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos. A presente situação não se amolda, todavia, a esta regra, lembrando que o réu negou o tráfico de drogas, não havendo, do mesmo modo, outros indicativos seguros da ocorrência do comércio espúrio pelo acusado.

Não se trata aqui, de forma alguma, de desqualificar todo e qualquer testemunho prestado por policiais, mas de não olvidar ou ignorar o julgador a possibilidade de ocorrência de falhas perpetradas por estes no exercício de sua função, que podem até incluir imputações precipitadas, pouco apuradas, apressadas ou mesmo injustas. Em toada semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - NECESSIDADE - PALAVRA ISOLADA DOS POLICIAIS. A versão policial isolada sobre a prática do crime não forma conjunto probatório suficiente para sustentar a convicção sobre a destinação da droga apreendida e, portanto, não autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.16.010381-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018).

Neste sentido também é o ensinamento de Gustavo Badaró:

Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do artigo 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelos simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por ele investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se demonstrem harmônicos entre si (BADARÓ, Gustavo Henrique; Processo Penal. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 477/478). (Grifos nossos)

Em sentido semelhante ao aqui exposto, esclarece, de forma muito didática, Aury Lopes Jr:

Da mesma forma, não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse

depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.

Contudo, é recorrente o Ministério Público arrolar como testemunhas apenas os policiais que participaram da operação e da elaboração do inquérito. Busca, com isso, judicializar a palavra dos policiais para driblar a vedação de condenação "exclusivamente" (art. 155 do CPP) com base nos elementos informativos colhidos na investigação. Na continuação, deparamo-nos com sentenças condenatórias em que são utilizados os elementos do inquérito e o depoimento dos policiais em juízo.

No fundo, é um golpe de cena, um engodo, pois a condenação se deu, exclusivamente, com base nos atos da fase pré-processual e no depoimento contaminado de seus agentes, natural e profissionalmente comprometidos com o resultado por eles apontado, violando o disposto no art. 155 do CPP. Portanto, se não há impedimento para que os policiais deponham, é elementar que não se pode condenar só com base nos seus atos de investigação e na justificação que fazem em audiência." (2019, p.462)

Aliás, na linha do que está sendo exposto, se a ideia fosse tomar como absoluta e incontestável toda e qualquer declaração prestada por testemunhas policiais no bojo do processo penal, despicienda seria a instrução probatória e até mesmo a valoração da prova colhida pelo Juiz de Direito. A presunção de inocência, princípio que informa todo o sistema processual penal, e que está prevista como garantia constitucional, também seria invariável e inevitavelmente fulminada.

Outrossim, como este juízo sempre vem asseverando, não é demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a reunião de outros elementos probatórios que não se limitem à mera repetição das declarações dos policiais que efetivaram a prisão do acusado, até porque, como consignado alhures, é natural que estes objetivem legitimar, até inconscientemente, sua própria atuação. Por oportuno, não se pode deixar de registrar, em crimes de natureza diversa do ora apurado, a par dos depoimentos policiais, são em regra produzidos outros elementos de prova, de origens distintas, a exemplo de testemunhos de terceiros, oitiva da vítima, com reconhecimento de pessoa e de objeto, etc, o que sem dúvida contribui para a realização de uma instrução processual mais robusta, com possibilidade de uma construção mais sólida da culpabilidade do agente.

Por um outro viés, estes mesmos policiais já dispõem, nos dias atuais, de outros instrumentos e mecanismos aptos a robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, conferindo às suas declarações um caráter de veracidade quase irrefutável, como já se pôde constatar em outras oportunidades, em que os policiais se valeram, inclusive, de gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações. Aliás, é pouco compreensível que nos dias de hoje, no estágio em que se encontra a tecnologia, haja ainda uma utilização tão tímida de aparatos e instrumentos de captação e gravação das abordagens policiais.

Pontua-se também, mais uma vez, que não foi trazida qualquer testemunha distinta do policial que pudesse corroborar a versão acusatória, o que certamente robusteceria a prova acusatória. Neste sentido são as palavras do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:

Parece-nos cauteloso que o magistrado, visualizando, em processos de apuração de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, um rol de testemunhas de acusação formado somente por policiais, indague os mesmos a razão pela qual não se obteve nenhuma pessoa, como testemunha, estranha aos quadros da polícia. Essa verificação é essência, pois uma apreensão de drogas feita à vista de inúmeras pessoas, em local público, por exemplo, pode perfeitamente contar com o testemunho de pessoas que não sejam policiais. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2009, p. 353).

Assim, cumpre indagar, ante aquilo que foi exposto, se o quanto relatado pelo policial pode, na hipótese em tela, ser considerada uma prova robusta e coerente para fins de fundamentalmente arrimar uma condenação por tráfico de drogas. No entendimento deste Juízo, não é.

Forçoso, in casu, verificar que, tendo negado o réu a propriedade ou porte da droga em juízo, e não havendo qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Mercancia não comprovada - Indícios insuficientes para formar convicção nesse sentido - Réu preso em companhia de menor reconhecido e indicado como traficante - Ausência de atos seguros e concretos vinculando suas ações - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido - (TJSP, APELAÇÃO Nº: 990.09.047397-5 - COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA APTE WELLINGTON DA SILVA SANTOS APDO : Ministério Público).

Assim, a despeito da probabilidade da ocorrência do tráfico de drogas e mesmo que se considere pouco crível a versão apresentada pelo réu, o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação por tráfico de drogas pelo acusado.

Destarte, nesta fase processual, encerrada a instrução, se alguma dúvida existe deverá ser interpretada em favor do réu, conforme recomenda a boa técnica processual penal.

Como é cediço, em casos de dubiedade, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição da acusada como medida de justiça. Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2008, p.178/19):

"...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos."

"Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo"

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8,

No mais, conforme leciona o Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 150), membro do Ministério Público de São Paulo:

“A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva.

Quando se tem presente, salientou Malatesta, que a condenação não pode basear-se senão na certeza da culpabilidade, logo se vê que a credibilidade razoável – também mínima – da inocência, sendo destrutiva da certeza da culpabilidade, deve, necessariamente, conduzir à absolvição”.

Com efeito, uma sentença judicial condenatória deve ser embasada em elementos objetivos, contundentes e sólidos. Em verdade, para fins de condenação criminal, a intuição deste julgador não tem qualquer importância. Não basta a crença, deve haver certeza.

Novamente, colaciona-se o escólio do Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 15):

A respeito, obtempera Heleno Cláudio Fragoso que “a condenação exige certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de nossa mente em torno da existência de certa realidade”. Mesmo a íntima convicção do Juiz – pondera Sabatini –, como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação (g.n.), não é verdadeira e própria certeza (...); no lugar da certeza, em espécie tal, tem-se a simples crença.

O entendimento do nobre membro ministerial é de rara sabedoria e desmerece contestações.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a acusada CINTIA CRISTINA BORGES DA COSTA, qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei 11.343/06 e ABSOLVER o réu MAURÍCIO BARBOSA DE SOUSA de todas as imputações que lhe foram dirigidas, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena da ré.

Circunstâncias judiciais

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que a ré agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. A ré possui maus antecedentes (0007521-07.2013.8.26.0045 - fls. 323/326). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias também não se revelam desfavoráveis à acusada, lembrando que a quantidade e natureza da droga não apresentam expressão ou magnitude aptas a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante de tais considerações exaspero a pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 dias-multa, no menor valor legal.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência (1500525-25.2018.8.26.0535 - fls. 323/326), passando a pena para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, observando-se que a ré não faz jus à aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, já

que é reincidente.

Quanto à causa de aumento do artigo 40, inciso III da Lei de Drogas, respeitado o entendimento do representante do Ministério Público, impõe-se o afastamento da qualificadora (cometimento da infração em local próximo a estabelecimento de ensino ou sede de entidades desportivas), pois, na verdade, o que se vê nos autos é a citação de que a prisão aconteceu na arquibancada de um campo de futebol, sem qualquer outra indicação ou prova de que a ação da acusada estivesse direcionada ao público que frequentava esse local.

Dessa forma, o que se tem é simples presunção, que, com a devida vênia, não pode justificar o reconhecimento da qualificadora em questão se nada sugere a maior gravidade da ação.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

Tráfico de drogas Prisão em flagrante Entrega de entorpecente para terceiro Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras Responsabilidade comprovada Condenação mantida; Tráfico de drogas Proximidade de escolas e campo de futebol Ausência de prova de que o tráfico se destinava ao público desses locais Qualificadora - Inocorrência; Tráfico de drogas Crime equiparado aos hediondos Abalo evidente à ordem pública Regime fechado Cabimento Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Impossibilidade Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00092332620128260220 SP 0009233-26.2012.8.26.0220, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 25/03/2015, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 30/03/2015).

Regime prisional

A ré é reincidente e ostenta maus antecedentes, e considerando a pena imposta e o quanto preconiza o art. 33, § 2º e alíneas, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, observando-se também o disposto na Súmula 269 do STJ.

Deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, uma vez que, mesmo computado o tempo em que a ré esteve presa provisoriamente (12/10/2021 até a data atual), não haveria alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Alternativas penais

Não estão atendidas as condições previstas art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Direito de recorrer em liberdade

A ré vem respondendo presa ao processo e, no presente momento, levando-se em conta o édito condenatório e as penas aplicadas, é de rigor a manutenção da custódia cautelar, razão pela qual nego à acusada o direito de apelar em liberdade.

Disposições Gerais

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial. Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

f) Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.

g) Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreto a perda da integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

P.I.C.

Aruja, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA